

1527342-09.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS E MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. INAPLICÁVEL. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E INSUMOS PARA SUA FABRICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O princípio da consunção incide quando seja um dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527342-09.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527342-09.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320836/2020 - 31º D.P. VILA CARRAO, 15380329 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3577/20/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3578/20/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2320836 - 31º D.P.

VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS SUCKOW DE BARROS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

JOÃO PEDRO MACHADO ALVES (RG:38870172) e MATHEUS SUCKOW DE BARROS (RG: 39776102) foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, artigo 34, caput, da Lei Federal 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, porque no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 03h15, na Avenida Salim Farah Maluf, n.º 2211, Tatuapé, nesta cidade e comarca da capital, teriam transportado e trazido consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico),534,4g (quinhentos e trinta e quatro gramas e quatro decigramas) de

Tetrahydrocannabinol na forma de haxixe, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, no dia 27 de dezembro de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 03h15, na Avenida Salim Farah Maluf, n.º 2211, Tatuapé, nesta cidade e comarca da capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de designios e propósitos, teriam transportado e possuíam aparelhos e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 06), sendo convertida a prisão em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 80/84).

Sobreveio decisão que concedeu liberdade provisória aos acusados (fls. 185/188).

Os réus foram citados (fls. 217/224), apresentando estes suas Defesas Prévias (fls. 243/249) e (267/285) e a denúncia recebida (fls. 303).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas; ao final, houve o interrogatório dos réus.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, para que o réu JOÃO PEDRO seja absolvido da imputação dos delitos previstos no artigo 33, caput e no artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, desclassificando sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06 e, para que o réu MATHEUS seja absolvido da imputação do artigo 34, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, condenando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

A Defesa do acusado João Pedro pleiteou a absolvição, nos termos dos incisos IV, V e VIII, do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: aplicação do princípio da consunção; desclassificação do delito do artigo 33 para o artigo 28; aplicação da pena de advertência.

A Defesa do corréu Matheus requereu que ele seja absolvido da imputação do artigo 34 da Lei de Drogas e seja realizado proposta de acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, requereu: o reconhecimento do tráfico privilegiado; a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão; afastamento da agravante da calamidade pública; fixação do regime inicial aberto; aplicação da detração e a possibilidade de recorrer em liberdade.

O Ministério Públicos se manifestou contrário à proposta do acordo de não persecução penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 22/28); auto de exibição e apreensão (fls. 35/36); laudo pericial (fls. 42/44; 169/171; 310/311; 312/314; 315/317; 318/320), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

Os policiais militares Erick Araújo Luz e Renan Menucci declararam extrajudicialmente que cumpriam escala de serviço, a bordo da viatura de prefixo T-02258, realizando um bloqueio policial no local dos fatos, até que resolveram abordar o veículo VW/Fox (placas TFP-4828), que tinha três ocupantes. Narraram que o motorista foi identificado como João Pedro Machado Alves, a passageira dianteira como Giulia Cardo Satyro, e, por fim, o passageiro do banco traseiro como Matheus Suckow de Barros, que trazia consigo um mochila preta. Submetidos à busca pessoa, em poder de João Pedro, em sua carteira, foi encontrada a quantia de R\$ 1.617,00, (mil seiscentos e dezessete reais) em espécie, que afirmou ser do recebimento de 13º salário de sua namorada. Disseram que em poder de Giulia Cardo, por sua vez, foi encontrada a quantia de R\$ 150,00, (cento e cinquenta reais) em sua bolsa, que, segundo ela, estava reservado para comprar presentes. Disseram que na mochila do indiciado Matheus Suckow, por outro lado, foi encontrado droga similar a haxixe, distribuída em quatro tabletes, além de outras duas porções grandes, todas de coloração escura e acondicionadas em plástico transparente, e uma balança pequena. Alegaram que então realizaram uma vistoria minuciosa no citado veículo e, debaixo do banco do motorista, dentro de uma gaveta, encontraram um estojo preto contendo mais duas porções de droga similar a haxixe, acondicionadas em plástico

transparente, alguns instrumentos pequenos (alicate, tesouras etc.) e o telefone celular do indiciado Matheus Suckow de Barros. Narraram que dentro do veículo também foram avistadas três caixas de pizzas. Assim que foram questionados sobre as drogas, João Pedro e Giulia Cardo disseram que não tinham conhecimento da existência da droga, e explicaram que apenas deram uma carona a Matheus Suckow, ao encontrá-lo na Pizzaria Dominus, pois Matheus conhece João Pedro por residirem próximos. Afirmaram que o denunciado Matheus Suckow de Barros, por sua vez, assumiu que toda a droga encontrada lhe pertencia e confirmou, ainda, que apenas pediu uma carona para João Pedro e sua namorada Giulia Cardo, ao encontrá-los na pizzaria, sendo que sobre o estojo preto debaixo do banco do motorista, contendo duas porções pequenas de drogas e o telefone celular do próprio denunciado, explica que havia pedido para João Pedro guardar para ele. Contaram que diante dos fatos, dirigiram todos para delegacia policial, para que fosse averiguado o caso. Em juízo o policial Renan afirmou que no dia dos fatos por volta das 3h da manhã estava realizando bloqueio na avenida e avistaram um carro FOX. Disse que quando determinou a parada do condutor, este apresentou nervosismo. Informou que tinha dois homens e uma mulher dentro do veículo. Relatou que todos estavam bem nervosos, e com passageiro do banco de trás, o acusado Mateus, foi visto uma mochila, e o motorista era o corréu João Pedro. Informou que não foi encontrado nada de ilícito em posse dos acusados. Contou que dentro da bolsa localizaram uma balança e tabletes, possivelmente drogas. Informou ter Mateus falado que as drogas eram dele e o motorista João estava bem nervoso. Asseverou que embaixo do banco do motorista tinha uma gaveta onde continha mais porções parecidas com entorpecentes. Narrou que com o motorista tinha uma quantia de R\$ 1600,00, tendo ele falado que era dinheiro de décimo terceiro. Informou ter encontrado R\$ 100,00 com moça. Relatou que a droga era haxixe e foi encontrada junto com apetrechos, sendo que os entorpecentes estavam envolvidos na mesma embalagem. Disse ter Mateus falado que estava guardando as drogas e o corréu João falou que nada era dele. Narrou que tinha caixas de pizza no carro. Afirmou ter a moça falado que não sabia de nada, mas o cheiro de drogas estava forte dentro do carro. Disse que os apetrechos eram tesoura de unha, alicate e balança de precisão, e esta estava dentro da mochila, mas os outros apetrechos estavam embaixo do banco do motorista. Informou que dentro da bolsa tinha quatro tabletes e porções pequenas e embaixo do banco duas esferas de drogas dentro do plástico. Contou que com o acusado Mateus assumiu as drogas as quais estavam dentro da bolsa.

A testemunha policial Erick afirmou em juízo que estavam fazendo bloqueio policial na avenida por volta das 3h da manhã quando viram o veículo Fox. Relatou que o motorista mostrou nervosismo e na abordagem verificaram que dentro do carro estavam o motorista João, a namorada e o outro acusado Mateus. Contou que na revista este tinha uma bolsa preta com quantidade de drogas as quais pareciam haxixe, sendo 4 tabletes e balança de precisão. Contou que o corréu João falou que não tinha conhecimento dessa droga e avisou que não tinha entorpecente no veículo. Relatou que verificaram embaixo do banco e localizaram mais drogas no formato redondo com apetrechos como pinça e alicate. Informou que junto com João tinha uma quantia de R\$ 1600,00 o qual aquele falou que era décimo terceiro. Disse que com a moça foi encontrado R\$ 100,00 ou R\$ 150,00. Asseverou ter os acusados falado que tinham saído de uma pizzaria e estavam indo para a casa. Informou que encontrou caixas de pizzas no carro. Narrou que os apetrechos foram encontrados embaixo do banco do motorista, junto com as drogas, dentro do estojo preto. Disse que na mochila encontraram 4 tabletes de drogas e porções menores. Informou que Mateus assumiu as drogas da mochila e o João falou que não sabia. Asseverou que o cheiro de droga dentro do carro estava muito forte. Disse ter o denunciado Mateus falado que João não tinha ciência das drogas.

A declarante Giulia Cardo Satyro afirmou extrajudicialmente que namora João Pedro há cerca de seis meses e na noite dos fatos João Pedro estava em sua casa na zona norte, quando resolveram pegar pizzas na pizzaria Dominus, em Moema. Disse que, em razão da pandemia, a pizzaria só entregava para viagem, motivo pelo qual seu namorado pegou as pizzas e, quando estavam para ir embora, um amigo dele, o qual a declarante desconhece e que também estava no local, pediu carona. Assim, relatou

que João Pedro deixou ele embarcar no banco traseiro do passageiro, e, então, comeram pizzas no carro mesmo e, na sequência, foram embora. Narrou que não deu muita atenção para o amigo de seu namorado, e nem prestou muito atenção na conversa dos dois, mas posteriormente soube se chamar Matheus. Disse que quando foram parados num bloqueio policial, os policiais encontraram drogas com Matheus, bem como em um estojo ou pochete preta que estava debaixo do banco do motorista do veículo de João Pedro. Narrou que gostaria de deixar claro que não tem qualquer relação com venda de drogas e que sequer sabia da existência das drogas, alegando que não conhece direito seu namorado e que não imaginava que ele era traficante também, que, somente sabia que ele era usuário de maconha, mas que ele não usava na sua frente, pois não concorda com isso; que sobre a quantia de R\$ 150,00, afirmou que o dinheiro é seu e que ganhou da mãe de João no Natal, para comprar presentes e sobre o dinheiro encontrado na carteira de João, alega que há alguns dias recebeu seu 13º salário e lhe entregou R\$1,000,00 (um mil reais) pois estariam planejando uma viagem no Ano Novo, mas que não pode afirmar se aquelas notas e aquela quantia que estava na carteira dele eram de fato as que lhe entregou semanas atrás.

Em juízo a testemunha Giulia afirmou que no dia dos fatos estava com o namorado João Pedro e decidiram comer pizza. Relatou terem ido à pizzaria em Moema, mas antes decidiram passar na casa de um amigo chamado Erick. Informou ter João falado que Mateus estava próximo e foram todos juntos para a pizzaria e para a casa do Erick, sendo que a mochila com as drogas já estava com o Mateus. Contou que os rapazes decidiram fumar maconha e depois foram para a pizzaria. Relatou que levaram a pizza para comer na casa do Erick. Informou ter voltado para a zona norte junto com Mateus. Relatou que foram parados pela blitz policial. Relatou que na revista os agentes públicos encontraram drogas dentro da mochila do Mateus e no carro, embaixo do banco, encontraram uma pochete com mais drogas. Tanto a mochila, como o estojo eram do acusado Mateus. Informou que não tinha ciência das drogas. Asseverou que ainda namora o réu João Pedro. Contou que nunca desconfiou que o réu João traficava, sendo que namorava há 06 meses desde o dia dos fatos. Disse que convivia quase diariamente com o réu João Pedro. Informou que quando eles saem, dividem a conta. Asseverou que o corréu Mateus entrou no carro a caminho da casa do Erick. Relatou que na carona já viram o acusado Mateus que estava com o estojo e a mochila. Disse que Mateus nunca falou que tinha drogas e não sentiu cheiro nenhum no veículo. Informou que o João era usuário de maconha e ele sempre trabalhou com o pai. Afirmou que o dinheiro encontrado com João era um valor do décimo terceiro da depoente para viajar junto com o réu, seu namorado. Disse que o acusado não ficava com o cheiro de droga. Relatou que não sabe quem forneceu a droga na hora que os acusado fumaram. Contou no momento da abordagem que viu os policiais retiraram a mochila e o estojo. Relatou ter visto o acusado Mateus entregando o estojo para o acusado João Pedro guardar.

A testemunha Marcelo Tadeu afirmou em juízo que o acusado Matheus, que é seu filho, é de família. Relatou ter Matheus conhecido as drogas na adolescência e é usuário desde então. Disse que nunca teve conhecimento do acusado ter traficado droga. Contou ter o acusado falado que comprou as drogas para uso próprio e dividiria com os amigos. Relatou que João Pedro deu carona e também é usuário, sendo que Mateus não sabia que tinha drogas também com ele.

A testemunha Marcos Vinicius afirmou em juízo que conhece o corréu Matheus há um tempo e este fazia faculdade no Mackenzie. Disse que o acusado se perdeu pelo uso de drogas. Informou que nunca teve relato de venda de drogas pelo acusado Matheus. O réu João Pedro Machado Alves, na fase extrajudicial, narrou que na data dos fatos foi com sua namorada Giulia à Pizzaria Dominus, na região de Moema, para comer pizza, que, inquirido sobre o porquê de ter ido tão longe para comprar pizzas, já que mora na zona norte e a pizzaria que foram era em Moema, na zona sul, o indiciado informou que foram naquele local porque a da zona norte estava fechada naquele horário, e porque primeiro passaram na casa de uma amigo no Jardim Anália Franco. Disse que, enquanto comprava as pizzas para comer no carro, já na pizzaria, seu amigo Matheus Suckow, apareceu, mas sem que tivessem combinado o encontro. Narrou que Matheus Suckow pediu uma carona, pois ambos moram perto um do outro e que, Matheus teria pedido para guardar um estojo preto e instado sobre o que teria

dentro, sabendo que era "fumo" (sic) e que, após comerem as pizzas dentro do carro, dirigiu-se para a zona norte, passando antes no bairro do Anália Franco, onde acontecia uma operação policial realizada na Av. Salim Farah Maluf. Contou que os policiais pararam seu veículo e abordaram todos os ocupantes, encontrando drogas na mochila de Matheus, que estava no banco de trás, e no estojo que o João guardara anteriormente, no compartimento embaixo de seu banco. Indagado sobre o porquê de Matheus ter pedido para guardar aquele estojo, ao invés de ter ficado com ele, já que também trazia consigo uma mochila, onde havia mais quantidade de entorpecente e uma balança, o interrogado disse que apenas guardou como o amigo pediu e que, sobre o haxixe encontrado e sobre o comércio ilegal de entorpecentes, disse que no passado teve envolvimento com drogas, mas que não mexe mais com isso, nega que sua namorada soubesse de qualquer coisa, além de afirmar que também não está envolvido com comércio ilegal praticado pelo amigo Matheus. Disse que, sobre a quantia encontrada em sua carteira, alega que uma parte é proveniente do 13º de sua namorada, que pediu para que guardasse consigo e o restante do dinheiro é seu. Em juízo o acusado João Pedro negou os crimes e afirmou que não tinha conhecimento das drogas as quais estavam com o corréu Matheus. Relatou que existia uma bolsa com Matheus e o depoente tinha R\$ 1.620,00, sendo que R\$ 1.000,00 da Giulia, R\$ 300,00 era da sua vó e os outros R\$ 300,00 eram do seu trabalho. Contou que o acusado João entregou uma pochete para colocar embaixo do banco. Informou que foram até a casa do amigo Erick para comer pizza, junto com a namorada Giulia, e no caminho deram carona para o corréu Mateus. Informou que Matheus falou que tinha um baseado para fumar e desceram do apartamento para fumar (o acusado e o Erick). Relatou que depois de ter fumado, foram comprar a pizza, exceto Erick por causa do filho pequeno. Disse que não viu as drogas com o corréu Matheus, nem mesmo os apetrechos. Contou que foi encontrado o celular e pochete embaixo do banco. Relatou que o dinheiro encontrado estava na carteira do depoente. Informou que não leu o depoimento extrajudicial e o corréu Matheus pediu para guardar o estojo e o celular. Relatou que é amigo do acusado Matheus há 01 ano. Disse que já estava há algumas semanas com o dinheiro na carteira. Informou que já fumou maconha com o acusado Matheus antes. Relatou que conhecia a ex-namorada e o Matheus há 06 anos. Informou que o outro corréu nunca abriu a bolsa ou a pochete. Disse que o pagamento da pizza foi dividido por 4 pessoas. Relatou que o corréu Matheus pediu perdão ao acusado. Informou que o réu Matheus trabalhava em uma empresa de arquitetura e nunca deu indícios de tráfico de drogas.

O réu Matheus Suckow de Barros disse extrajudicialmente que estava em sua casa, no bairro do Jardim Peri, zona norte, quando conversou pessoalmente com uma pessoa de nome Icaro, o qual disse que um amigo dele teria um "material" (sic) e iria viajar, pedindo então que o interrogado ficasse com o "material" até que retornasse de viagem; que, pelo serviço, o interrogado receberia uma quota para uso e sabendo que o "material" que buscaria era haxixe, o interrogado aceitou a proposta e foi ao encontro do amigo de seu colega Icaro, encontrando-se com ele na catraca do metrô Tatuapé. Disse que não sabe o nome dele, sabendo somente seu apelido "Batata". Narrou que foi até o local combinado e ficou esperando até que alguém o abordasse, porque não conhecia pessoalmente aquele rapaz que lhe entregaria a droga e que, por volta das 19h, um indivíduo de aproximadamente 40 anos, alto, pardo, com barba e de porte forte, lhe abordou e entregou uma sacola com as drogas e com uma balança e foi embora em seguida. Declarou que guardou o "material" em sua mochila e em uma pochete e se encontrou ali nas proximidades com seu amigo João e sua namorada, e foram para o apartamento de um outro rapaz de nome Erick, sendo que um tempo depois todos se dirigiram para a pizzaria Dominos, que fica em Moema, zona sul. Narrou que, após comprarem pizza e comerem em frente a pizzaria, todos retornaram, sendo que o interrogado foi com João e a namorada dele e que, quando estava no carro, pediu para João segurar a pochete com uma parte da droga, tendo ele por conta própria escondido embaixo do banco do motorista. Disse que João sabia das drogas, mesmo porque anteriormente, enquanto estavam no Tatuapé, os dois usaram o haxixe que havia acabado de pegar com o indivíduo de nome Batata. Alegou que a namorada de João não sabia e que quando fumaram o haxixe ela se encontrava no apartamento de seu amigo, não tendo presenciado nada. Mas que quando voltavam para a zona norte,

foram abordados por policiais em uma operação, os quais encontraram o entorpecente que estava na mochila e na pochete que seu amigo guardara embaixo do banco. Afirmou que não iria comercializar o haxixe com João Pedro, porque o combinado era somente guardar para o indivíduo chamado Batata, até que ele voltasse de viagem e que, inquirido sobre a qualificação ou o endereço de Icaro e Batata, o interrogado afirma que desconhece qualquer informação sobre os dois.

Em Juízo o acusado Matheus afirmou que estavam transportando as drogas e grande parte era do acusado. Informou que um colega deu a oportunidade de transportar os entorpecentes e iria receber um dinheiro. Contou ter encontrado com a Giulia e o corréu João Pedro para comer pizza e posteriormente foram parados pela polícia. Informou que tinha uns recipientes para armazenar o haxixe, duas tesouras e uma balança. Relatou que possuía uma mochila preta na qual tinha a balança de precisão, quatro tablets de haxixe e duas porções pequenas as quais tinha separado para fumar. Relatou que foi encontrado embaixo do banco do acusado João Pedro uma pochete e dentro dela com duas tesouras, dois sliquipedes e duas porções de drogas. Informou que receberia um dinheiro para transportar as drogas, tendo recebido os entorpecentes no metrô Tatuapé e iria ser combinado o destino posteriormente. Disse que o acusado João Pedro não tinha o conhecimento das drogas da mochila. Relatou que não era dono da pochete, ou das drogas ou utensílios encontrados nelas. Relatou que jogou o seu celular embaixo do banco do motorista. Contou que não conversaram sobre o conteúdo da mochila. Asseverou que tinham 02 cuias, 02 sliquipedes e 02 tesouras no estojo e conseguiu ver isso quando os policiais mostraram. Asseverou que não sabe se as drogas da mochila eram as mesmas da pochete. Disse que não conferiu se com as drogas tinham algum outro objeto. Informou ter assumido todas as drogas na delegacia porque tinha combinado com o corréu, mas não era verdade. Relatou que conhecia o réu João Pedro de balada e nunca ficou sabendo se ele traficava.

Depreende-se das circunstâncias do flagrante e ainda pela quantidade de droga apreendida, ser inconteste a prática do crime do tráfico pelo acusado Matheus. A prova oral hoje produzida também aponta de maneira certa para o fato de que o acusado era possuidor dos entorpecentes que foram encontrados dentro da mochila. Os policiais detalharam ter parado um veículo o qual era dirigido pelo corréu João Pedro, sendo que o acusado Matheus estava sentado no banco de trás. Nada de ilícito foi encontrado com eles, mas em uma mochila pertencente ao denunciado Matheus foram encontrados 4 tablets de maconha e pequenas porções de entorpecentes embaixo do banco do motorista. Afirmam ainda que ele confessou o transporte das drogas e o acusado João disse que não sabia dos entorpecentes.

O laudo pericial definitivo concluiu que a substância apreendida trata-se de TETRAHIDROCANNABINOL (fls.169/171).

A quantidade de drogas apreendidas não demonstra que se trata de usuário. Além disso, o corréu Matheus confessou em juízo que transportava as drogas encontradas na mochila.

No entanto, em relação ao acusado João, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecentes encontrada embaixo do banco do motorista com alguns petrechos, além do próprio corréu João afirmar que não tinha ciência dos entorpecentes transportados pelo outro acusado e alegar ser usuário, somente é possível condenar o corréu João por aquilo que ficou provado, razão pela qual, por cautela, o caminho mais razoável é a desclassificação para o crime de posse/porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em relação ao preceito do artigo 34 da Lei 11.343/06, entende-se que os objetos encontrados foram usados para a preparação dos entorpecentes localizados no veículo. Nesse sentido, aplica-se o princípio da consunção na medida em que o crime do dispositivo mencionado serve de meio necessário para a execução de outro crime, não podendo se caracterizar uma conduta autônoma dos réus. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS E MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. INAPLICÁVEL. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E INSUMOS PARA SUA FABRICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O princípio da consunção incide

quando seja um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos. Entre os delitos de tráfico de drogas, de seus insumos ou maquinário, pode ocorrer a consunção quando constatado que sejam os insumos ou maquinários confirmados como meios de obtenção da droga comercializada, o que se evidencia no caso dos autos. 2. A minorante foi afastada em razão da expressiva quantidade da droga apreendida - 1.525 comprimidos de ecstasy -, bem como na apreensão de significativa quantidade de matéria-prima para a fabricação do entorpecente - 305,5g de pó contendo MDMA e 3480,7g de lactose e celulose -, não se verificando manifesta ilegalidade. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, o que se verifica no caso dos autos. 4. Habeas corpus concedido parcialmente para absolver o paciente do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006, mantendo a condenação pelo tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei, nos termos da sentença atacada. (HC 598.863/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020) (grifo nosso)

Passa-se à aplicação da pena.

Em relação ao corréu Matheus.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, expressiva a quantidade de drogas apreendidas. Assim, fixo a pena-base do tráfico em 1/6 acima do mínimo legal, o que atinge 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, diminuindo a pena em 1/3. Contudo, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavírus disease 19 - COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. No caso, estamos diante de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é a saúde pública; então, transportando o mesmo raciocínio acima, entende-se que a agravante em questão somente seria aplicada se ficasse comprovado, de maneira evidente e não por argumentações gerais, que houve alguma facilidade para o agente praticar o tráfico de drogas. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público nas

alegações finais.

Inexiste causa de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal. O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

Em relação ao acusado João Pedro, diante da desclassificação do crime de tráfico para a conduta de usuário, conforme fundamentado acima e considerando que o acusado não é reincidente, mas já foi condenado por ser usuário (fls.68/69), deverá ele cumprir 04 meses de prestação de serviço à comunidade, sendo suficiente a medida aplicada tendo em vista as condições pessoais do denunciado e as penas elencadas no artigo 28 da Lei de Drogas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para:

(A) CONDENAR o corréu MATHEUS SUCKOW DE BARROS (RG: 39776102), qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar estabelecido, sendo que a pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido;

(B) ABSOLVER, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, os réus JOÃO PEDRO MACHADO ALVES (RG:38870172) e MATHEUS SUCKOW DE BARROS (RG: 39776102), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 34, caput, da Lei nº 11.343/06;

(C) DESCLASSIFICAR a conduta do réu JOÃO PEDRO MACHADO ALVES (RG:38870172) da forma do art. 33 da Lei 11.343/2006 para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006, e, por consequência, condeno o acusado a cumprir: prestação de serviços à comunidade por 4 (quatro) meses.

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de terem respondido ao processo nessa condição.

Oficie-se para destruição das drogas.

Considerando a desclassificação e absolvição do acusado João Pedro, defiro o levantamento do valor apreendido com ele.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Gerdinaldo Quichaba Costa
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA